

1504977-67.2020.8.26.0322

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504977-67.2020.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504977-67.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302089/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 15035264 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5925/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5936/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5925/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5936/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2302089 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Asael Estevão Nogueira dos Santos

Juiz de Direito: Dr. LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recebida a denúncia, ofertada resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com produção de prova oral e interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 177/182).

A Defesa quer a consideração das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa. Pleiteia o perdão judicial. Em caso de eventual condenação, pede substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação do regime aberto. Requer a devolução do aparelho celular e da quantia apreendida proveniente do auxílio emergencial (fls. 187/204).

É o relatório.

DECIDO

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl.1, boletim de ocorrência de fls. 3/4, imagens de fls. 18 e 25, pelo laudo pericial definitivo de fls. 81/83, laudo pericial de fls. 84/88, não se olvidando da prova oral coligida.

3. Passo à análise da prova oral.

A testemunha de acusação Edson Danilo Brandão da Costa, policial civil, na fase inquisitorial, disse que o setor de investigação estava recebendo denúncias de tráfico de drogas na Rua Alexandrino Figueiredo, próximo da praça. Foram até o local e avistaram um indivíduo no mesmo local da denúncia. Realizaram a abordagem. O réu estava com 9 porções semelhantes a "crack", uma carteira com R\$210,00 em espécie e um celular. Identificaram que o indivíduo era o mesmo citado nas denúncias. O réu alegou que estava traficando no local há duas semanas, e que a quantia em dinheiro era proveniente do tráfico. Após a chegada do apoio, foram até a casa de Asael. Miriã, prima do réu, franqueou a entrada no local. O réu informou o local onde estavam mais três pedras de "crack" e fragmentos da substância ilícita. Wisley continuou as buscas e localizou R\$605,00 em espécie, debaixo de uma almofada no sofá. Encontraram também diversos sacos plásticos do tipo "juju". As diligências foram acompanhadas por Miriã. O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para a CPJ (fl. 7). Em juízo ratificou a versão e acrescentou que o local é conhecido pela prática de tráfico de drogas. Foram até o local para a realização de diligência. Abordaram o réu e localizaram com ele entorpecentes e dinheiro. Asael confessou a prática do delito. Questionado, o réu afirmou ter mais drogas em sua casa. Foram até a residência do acusado, onde localizaram três pedras de crack maiores e R\$605,00. Asael informou que o dinheiro localizado em sua carteira era proveniente do tráfico e a quantia de R\$605,00 era proveniente do auxílio emergencial. Informalmente, Asael informou que havia adquirido a droga de um indivíduo de Getulina/SP. Localizaram também na residência sacos plásticos do tipo "juju". Não se recorda dos valores das cédulas encontradas na residência do réu. Asael não ofereceu qualquer resistência (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Wisley Moraes Gonçalves Silva, policial civil, na fase inquisitorial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (fl. 8). Em juízo, manteve a versão, asseverando que estavam recebendo várias denúncias de tráfico de drogas no local dos fatos. Foram até o local. Visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, então decidiram pela abordagem. O réu estava com 9 pedras de "crack", aproximadamente R\$200,00 em espécie e um aparelho celular. Asael confessou o crime. O réu informou que havia mais droga em sua residência. Miriã, prima de Asael, franqueou a entrada na casa. Localizaram três pedras de "crack" em cima de um sofá. Encontraram também sacos plásticos comumente utilizados para embalo de drogas e a quantia de R\$605,00 em dinheiro. Asael alegou que o dinheiro era proveniente do auxílio emergencial. Não se recorda dos valores das cédulas encontradas na casa do réu (mídia digital/SAJ). O réu, em solo policial, confessou o delito. Comprou os entorpecentes de uma pessoa de Getulina/SP. Indicou para os policiais civis a existência de mais drogas em sua casa. Franqueou a entrada. O dinheiro localizado em sua residência é proveniente do auxílio emergencial, e pode provar isso futuramente. Está arrependido. Não sofreu ofensas à sua integridade física ou moral (fls. 10). Em juízo, confirmou os fatos. Estava vendendo drogas. Trabalhava na "JBS", mas o contrato havia se encerrado, então ficou desempregado no início da pandemia. Tentou ingressar no exército, sem sucesso. Resolveu vender drogas. Perdeu várias oportunidades, por causa do tráfico. Estava com a "mente fraca". Ia até o local fumar, até que certo dia conheceu um indivíduo de Getulina/SP. Aceitou comercializar entorpecentes. Estava traficando há duas semanas. Decidiu cooperar com a abordagem, pois sentiu-se ameaçado. Arrependeu-se muito. Perdeu duas oportunidades de emprego por estar sendo processado criminalmente. Atualmente está trabalhando como marceneiro. Não quer passar por essa experiência novamente. Ainda usa maconha. Toda a droga que possuía era para comercialização. Nunca havia sido preso. Era muito dedicado na época da escola. Está fazendo um curso do "Senai". Inscreveu-se em um curso de informática.

Ficou preso por 40 dias. Arrependeu-se dos fatos (mídia digital/SAJ).

4. De início cumpre destacar que o ingresso dos policiais na residência do acusado não restou amparada por mandado judicial ou em fundadas razões, em sintonia com entendimentos jurisprudenciais mais recentes do STJ e do STF:

Segundo teses firmadas, inclusive, com repercussão geral reconhecida – RE 603616 RO, a obediência ao devido processo legal de conhecimento penal deve observar a conhecida inviolabilidade do domicílio, com critérios seguros, ou seja, mediante autorização escrita e gravada por mecanismo audiovisual do morador, para as hipóteses em que não há mandado judicial competente.

Veja:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso – Decisão: Após o relatório e a sustentação oral, pelo amicus curiae Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Denis Sampaio, Defensor Público do Estado, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.11.2015. Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese. Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, participando como palestrante do XVI Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamerica, em Havana, Cuba, e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015” (STF, REExt 603.616/RO, Trib. Pleno, Repercussão geral mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. DJe 093 10/06/2016).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que 'a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial'.

1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, exortação de Conde Chatham, ao dizer que: 'O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!' ('The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!') William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência cuja urgência em sua cessação demande ação imediata é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação amiúde irreversível de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.

5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.

5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (in dubio libertas). O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ('consent, to bẽ valid, 'must bẽ unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances).

6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.

6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUÁ, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North

Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579).

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, 'necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis' (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial ao dispor que, 'finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º'.

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação como ocorreu no caso ora em julgamento de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.

7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.

8.1. As decisões do Poder Judiciário mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para 'enriquecer o estoque das regras jurídicas' (Melvin Eisenberg. The nature of the common law. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.

8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a

admissibilidade das provas ilícitas (Weeks v. United States, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ('such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action').

8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.

9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.

10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal" (STJ, Sexta Turma, HC. 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 02/03/2021).

Portanto, apenas no que toca ao entorpecente e ao dinheiro localizados na residência do réu (R\$605,00 e 3 porções de "crack"), uma vez que não comprovada a autorização para o ingresso na casa, realização de investigação prévia ou uma campanha, esta parte da prova deve ser anulada, por se originar de um ato abusivo e, portanto, ilícito, ante a violação de garantia constitucional.

Sem que isso transpareça crítica ao trabalho dos policiais ou às declarações por eles prestadas, de acordo com o posicionamento referendado, nesses casos, simples declaração de que houve consentimento informal do morador, para cancelar tal ingresso, não é suficiente. Isso porque a inviolabilidade do domicílio se vincula ao direito à intimidade do indivíduo e de seu grupo familiar, justificando criterioso tratamento para evitar ações indiscriminadas e arbitrárias de toda ordem.

Ainda que as versões dos policiais fossem albergadas, nota-se que o consentimento do morador não foi colhido segundo os requisitos apontados, a fim de atestar com

segurança, por meio de registro “cabal”, sua legalidade e voluntariedade necessárias.

5. De outro lado, no tocante às porções de “crack” (9), dinheiro (R\$215,00) e o celular encontrados na posse do réu, bem se caracterizou o flagrante delito, restando incólume a prova, nessa parte.

Assim, além das demais provas válidas carreadas aos autos, o réu confessou os fatos, aduzindo que as porções de “crack” e o dinheiro que trazia consigo tinham relação com o tráfico de drogas.

A confissão foi espontânea, com objetivo de elucidar o fato, bem como verossímil, certa, clara e coincidente com os outros elementos angariados nos autos.

Em acréscimo, o laudo pericial acostado confirmou a natureza do entorpecente apreendido.

Como se viu, não resta dúvida de que Asael praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, que restou suficientemente comprovado.

A condenação é medida que se impõe, nos moldes acima.

6. É caso de se aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 ao réu.

Ele é primário e de bons antecedentes e, pelo que ficou apurado, não se dedica à atividade criminosa reiterada ou está ligado a organização criminosa.

O benefício, desta forma, não pode ser excluído, subsistindo o entendimento de que o fato se traduziu em algo pontual na vida do denunciado, que, assim, faz jus ao benefício em debate.

Quanto à redução, considerando-se a margem legal e os detalhes envolvidos no crime, que envolve pequena quantidade de droga, aplico a redução no patamar máximo.

7. Passo à fixação da pena.

Primeira fase: as condições do art. 59 do CP são favoráveis ao réu (ausentes maus antecedentes). Penas no mínimo.

Segunda fase: a atenuante da confissão espontânea fica reconhecida, bem como a atenuante da menoridade relativa, no entanto, estas não possuem o condão de trazer as penas para aquém do mínimo legal cominado nesta fase. Mantidas, pois, no mínimo. Terceira fase: em razão da incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduz a pena em 2/3, segundo restou fundamentado.

A reprimenda perfaz 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no mínimo.

7.1. Do regime carcerário.

Considerando que o crime em questão constitui o chamado “tráfico privilegiado”, dada a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Isso porque, em consonância com o julgamento proferido pelo plenário do STF, nos autos do HC nº 118.533, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 23/06/2016, o tráfico privilegiado não é crime equiparado a crime hediondo, razão pela qual não há de se falar em aplicação da Lei nº 8.072/90.

Neste sentido, vale mencionar o referido julgado:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:

INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (STF, HC. 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.23.06.2016).

Em consonância com o referido posicionamento, o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.

ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS.

REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA

TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA

CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria 'contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa' (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (STJ, Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2), 3ª Seção, REL. MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016). Nos moldes do quanto decidido nos julgados declinados, configurado o "tráfico privilegiado", os rigores legais devem ser mais brandos, inclusive para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, sob pena de evidente constrangimento ilegal, o que fica reconhecido na presente hipótese. Assim, o regime será o ABERTO, podendo haver regressão para o semiaberto e para o fechado.

7.2. Ainda, CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por RESTRITIVA DE DIREITOS.

Acompanhando as razões já expostas, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o tráfico privilegiado não se equipara a crime hediondo, de modo que a aplicação do art. 44 do CP não está desautorizada, desde que, por óbvio, restem preenchidos seus requisitos, objetivos e subjetivos. E isso se amolda à hipótese.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial que adoto:

"1. Nulidade Inépcia da denúncia - Não configuração. 2. Tráfico - Suficiência probatória - Condenação mantida. 3. Associação - Estabilidade e permanência não demonstradas - Absolvição. 4. Penas - Quantidade e natureza das drogas consideradas para elevar as básicas e negar o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - "Bis in idem" - Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo. 5. Atenuantes - Redução aquém do piso - Impossibilidade - Súmula 231 do STJ. 6. Privilégio - Cabimento, afastada a associação - Redução de 1/5 por conta da quantidade e variedade dos tóxicos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 7. Multa - Inconstitucionalidade - Não ocorrência. 8. Regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos - Possibilidade - Tráfico privilegiado não incluído no rol dos crimes hediondos ou equiparados - Súmula 718 do STF (...)

Identificada a forma privilegiada da infração e aplicada pena reclusiva não superior a quatro anos, os recorrentes fazem jus à substituição da reprimenda por prestação de serviços à comunidade e multa de 10 (dez) diárias, no piso, nos termos do art. 44 do Código Penal. Observe-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS" (TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0001490-62.2017.8.26.0616, Rel. Vico Mañas, v.u., j. 11/11/2019) - destaquei.

Logo, com fundamento no art. 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consistentes em duas penas de prestação de serviços à comunidade, a serem fixadas na execução, nos moldes do art. 46 do CP.

No caso de descumprimento das restritivas o regime será o ABERTO, podendo haver regressão para o semiaberto e o fechado, com o perdão da repetição.

5. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para condenar ASael ESTEVÃO NOGUEIRA DOS SANTOS a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no mínimo, em regime inicial ABERTO, substituída a pena corporal por restritivas de direito, consistentes em duas (2) penas de prestação de serviços à comunidade, definidas na execução, nos moldes do art. 46 do CP, como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos das N.S.C.G.J, autorizo a incineração da substância entorpecente apreendida nestes autos, devendo ser preservada quantidade suficiente para eventual exame pericial e de contra prova.

Decreto, ainda, o perdimento dos bens e/ou dos valores apreendidos na posse do réu (R\$210,00 - duzentos e dez reais e um aparelho celular Motorola de numeração 359102101953413), conforme a denúncia, em favor da União, pois não há dúvida da utilização deles no crime em questão, por tudo o que se disse acima.

QUANTO AO VALOR DE R\$605,00 (SEISCENTOS E CINCO REAIS), APREENDIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA, TENDO TAL PROVA SIDO CONSIDERADA NULA, PROVIDENCIE-SE O NECESSÁRIO PARA SUA DEVOLUÇÃO AO RÉU.

Com o trânsito em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando o réu isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA